

次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討し、正しい場合には1を、誤っている場合には2を選びなさい。

- ア. 甲は、客観的にわいせつ性を有する書籍につき、その内容を確認して理解したものの、この程度では刑法上のわいせつな文書には該当しないと考え、同書籍を多数の者に販売した。この場合、甲にわいせつ物頒布罪は成立しない。
- イ. 甲は、A方前路上に置かれていた自転車を、Aの所有物と認識して持ち去ったが、実際には同自転車は捨てられた物であり、誰の所有にも占有にも属さないものであった。この場合、甲に遺失物等横領罪が成立する。
- ウ. 甲は、男性Aが、酩酊して暴れ回る女性Bを介抱するために取り押さえているのを見て、AがBに対し無理矢理わいせつ行為に及ぼうとしていると誤信し、Bを助けるため、自己の暴行の内容を認識しつつAに暴行を加え、傷害を負わせた。甲の暴行の程度が、甲が認識した急迫不正の侵害に対する防衛手段としての相当性を超えていた場合であっても、甲に傷害罪は成立しない。
- エ. 甲は、乙に対し、A方に侵入して金品を窃取するように唆したところ、乙は、犯行を決意し、A方に侵入しようとしたが、施錠を解錠できず、犯行を断念した。帰路において、乙は、B方に侵入し、Bから金品を強取した。甲の教唆行為と乙のB方における住居侵入及び強盗との間に因果関係が認められない場合であっても、甲に住居侵入罪及び窃盗罪の教唆犯が成立する。
- オ. 甲は、乙が窃取したバッグを、これが盗品かもしれないがそれでも構わないと思って購入した。この場合、甲に盗品等有償譲受け罪が成立する。

No54	犯罪の成立要件						正答率
R5-1	正解	ア 2	イ 2	ウ 2	エ 2	オ 1	47%

ア 誤っている

本記述は、わいせつ物頒布罪は成立しないとしている点で、誤っている。

最大判昭 32.3.13 (百選 147 事件) は、被告人が、性的描写のある外国の文学書をその内容を知りつつ翻訳出版したという事案において、「175 条の罪における犯意の成立については問題となる記載の存在の認識とこれを頒布販売することの認識があれば足り、かかる記載のある文書が同条所定の猥褻性を具備するかどうかの認識まで必要としているものでない。かりに主観的には刑法 175 条の猥褻文書にあたらないものと信じてある文書を販売しても、それが客観的に猥褻性を有するならば、法律の錯誤として犯意を阻却しない」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、わいせつ物頒布等罪 (175 条) における「わいせつ」性は、規範的構成要件要素の 1 つであり、故意が成立するためには、「わいせつ」に当たるという法的概念への当てはめは不要だが、違法・責任評価の基礎となる事実の社会的意味内容の認識、すなわち「いやらしい、みだらな記述」というように、一般人が性的興味を抱くような意味内容の文書であるという社会通念上の意味の認識 (この意味の認識が欠ければ事実の錯誤となる) があれば足りるということを挙げている。よって、本記述においては、甲が、本件書籍はわいせつな文書に該当しないと考えていても、客観的にわいせつ性を有する本件書籍の内容を確認して理解した上でこれを多数の者に販売している以上、わいせつ物頒布罪 (175 条 1 項) の故意が認められ、同罪が成立する。

イ 誤っている ★

本記述は、遺失物等横領罪が成立するとしている点で、誤っている。

254 条は、「遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物」を客体と規定している。「占有を離れた他人の物」とは、占有者の意思に基づかずにその占有を離れた物で誰の占有にも属していないもの、及び、委託関係に基づかないで行為者の占有に属したものをいうと解されている。すなわち、他人の所有に係る物であることが前提であり、他人が所有権を放棄した物や無主物は本罪の客体とはならない。最判昭 25.6.27 も、本罪の客体が他人の所有に係るものであることを前提にしている。よって、本記述においては、甲が、本件自転車を A の所有物と認識して持ち去ったのだとしても、実際は、本件自転車は誰の所有にも属さないものであったことから、本件自転車は遺失物等横領罪 (254 条) の客体とはならず、同罪は成立しない。

ウ 誤っている

本記述は、傷害罪は成立しないとしている点で、誤っている。

最決昭 62.3.26 (百選 129 事件) は、酩酊した B 女とこれをなだめていた A 男とが揉み合っている場面を目撃した被告人が、A 男が B 女に暴行を加えているものと誤信し、B 女を助けるべく、A 男の顔面付近に回し蹴りをし、よって A 男を死亡させたという事案において、「右事実関係のもとにおいて、本件回し蹴り行為は、被告人が誤信した A による急迫不正の侵害に対する防衛手段として相当性を逸脱していることが明らかであるとし、被告人の所為について傷害致死罪が成立し、いわゆる誤想過剰防衛に当たるとして刑法 36 条 2 項により刑を減輕した原判断は、正当である」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、急迫不正の侵害が存在すると誤信していても、過剰性の認識が存在する以上、正当防衛の主観面を備えているとはいえず、故意犯が成立するという事を挙げている。よって、本記述においては、甲が、B に対する急迫不正の侵害を誤信していたとしても、その防衛手段として相当性を超える自己の暴行内容を認識しつつ A に暴行を加えていることから、過剰性の認識が存在するといえ、傷害罪 (204 条) の故意は阻却されず、同罪が成立する。

エ 誤っている ★

本記述は、住居侵入罪及び窃盗罪の教唆犯が成立するとしている点で、誤っている。

本記述では、まず、甲が乙に唆したのは、A方における住居侵入窃盗であるところ、実際に乙が行ったのは、B方における住居侵入強盗であることから、共犯の錯誤が問題となる。

最判昭 25.7.11 (百選 191 事件) は、本記述と類似の事案において、「犯罪の故意ありとなすには、必ずしも犯人が認識した事実と、現に発生した事実とが、具体的に一致 (符合) することを要するものではなく、右両者が犯罪の種類 (定型) として規定している範囲において一致 (符合) することを以て足る」とし、また、「被告人甲は住居侵入窃盗の範囲において、右乙の強盗の所為について教唆犯としての責任を負うべきは当然であつて、被告人甲の教唆行為において指示した犯罪の被害者と、本犯たる乙のなした犯罪の被害者とが異なる一事を以て、直ちに被告人甲に判示乙の犯罪について何等の責任なきものと速断することを得ない」としている。本判例の事案は、正犯の実現した事実が、教唆者が認識・予見した事実と異なった構成要件間にまたがった抽象的事実の錯誤の場合であるが、法定的符合説 (抽象的法定符合説) の見地から、軽い窃盗罪の限度で教唆犯の成立が認められることになる。また、被害者が異なるという点についても、教唆者にとっては方法の錯誤と解することになり、こちらも法定的符合説 (抽象的法定符合説) の見地から、故意が認められることになる。

本記述では、次に、甲の教唆行為と乙のB方における住居侵入強盗との間に因果関係が認められない場合の帰結が問題となる。

本判例は、「いやしくも右乙の判示住居侵入強盗の所為が、被告人甲の教唆に基いてなされたものと認められる限り」教唆犯が成立するとし、教唆行為と被教唆者が実行した犯罪との間に因果関係が必要であるとしている。これは、判例・通説である共犯従属性の立場から当然の要件であるとされている。よって、本記述では、甲の教唆行為と乙のB方における住居侵入強盗 (130 条前段、236 条1項) との間に因果関係が認められない場合には、甲に教唆犯 (61 条1項) は成立しない。

なお、正犯が教唆行為に基づく決意を一旦放棄して、決意を新たに犯罪を実行した場合には、もはや当初の教唆行為による犯罪促進作用は及んでおらず、教唆犯における因果関係は認められないことになると考えられている。本判例でもこの点が問題となった。

オ 正しい

最判昭 23.3.16 (百選 141 事件) により、本記述は正しい。

判例は、被告人が、外国人から、その頃他人が窃取した衣類を買い受けたという事案において、「赃物故買罪〔注：現盗品等有償譲受け罪〕は赃物〔注：盗品〕であることを知りながらこれを買受けることによつて成立するものであるが、その故意が成立する為めには必ずしも買受べき物が赃物であることを確定的に知つて居ることを必要としない或は赃物であるかも知れないと思ひながらしかも敢てこれを買受ける意思 (いわゆる未必の故意) があれば足りる」とした上で、「たとえ買受人が売渡人から赃物であることを明に告げられた事実が無くても苟くも買受物品の性質、数量、売渡人の属性態度等諸般の事情から『或は赃物ではないか』との疑を持ちながらこれを買受けた事実が認められれば赃物故買罪が成立する」としている。よって、本記述においては、甲が、本件バッグを盗品であると確定的に認識していなくとも、それが盗品かもしれないと思って購入している以上、盗品等有償譲受け罪 (256 条2項) の (未必の) 故意が認められ、同罪が成立する。